

1501392-71.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/08/2022
... Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
3ª Vara Criminal
Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana
CEP: 13088-901 - Campinas - SP
Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1501392-71.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501392-71.2021.8.26.0548
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Indiciado:
JOÃO MAURICIO COUTINHO GUIMARÃES JUNIOR e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

ANTÔNIA DE FERREIRA CARVALHO BAUDUINO, JOÃO MAURÍCIO COUTINHO GUIMARÃES JÚNIOR e FELIPE FERNANDES BARBOSA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 10h30min, no Centro de Progressão Provisória - Penitenciária Ataliba Nogueira, localizado na Rodovia SP 101, Km 5, Parque Santa Bárbara, nesta cidade comarca de Campinas/SP, ANTONIA DE FERREIRA CARVLHO BAUDUINO trazia consigo e entregou aos detentos JOÃO MAURÍCIO COUTINHO GUIMARÃES JÚNIOR e FELIPE FERNANDES BARBOSA respectivamente, 04 (quatro) segmentos de papel de cor branca, contendo ADB-BUTINACA, constante da

lista F2 (Lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) por sua classe estrutural dos canabinoides sintéticos da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), droga popularmente conhecida como "K4", e 09 (nove) segmentos de papel de cor amarela, contendo a mesma substância conhecida como "K4", pesando 34,9g (trinta e quatro gramas e nove decigramas), sendo que, no interior de um veículo "taxi", estacionado próximo ao presídio, ANTONIA DE FERREIRA CARVLHO BAUDUINO também transportava e guardava, para fins de tráfico, mais 03 (três) segmentos de papel de cor amarela, contendo a substância ADB-BUTINACA, pesando 40,1g (quarenta gramas e um decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, na mesma ocasião, no interior da Penitenciária Ataliba Nogueira, JOÃO MAURÍCIO COUTINHO GUIMARÃES JÚNIOR e FELIPE FERNANDES BARBOSA foram surpreendidos quando traziam consigo as porções de substância entorpecente acima mencionadas, que receberam de ANTONIA DE FERREIRA CARVLHO BAUDUINO, destinadas à entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os acusados foram notificados (Felipe - fls. 213; João - fls. 214) e apresentaram Defesa Prévia. A denúncia foi recebida (fls. 255/256) e os réus foram citados. Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente, em parte.

As provas carreadas aos autos comprovam que a ré Antônia praticou o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado, devendo os réus João e Felipe serem absolvidos da imputação que lhes foi feita na peça acusatória.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 18/21, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 131/139, positivo para ADB-BUTINACA.

Quando interrogado, em Juízo, o réu Felipe negou os fatos. Disse que pediu a indicação de um advogado e um preso de nome Romildo indicou a corré Antônia. Contou que conversou com a corré Antônia para que entrasse com pedido em seu nome, já que estava com problemas de saúde, mas, em razão da demora, sua esposa conseguiu outro advogado. Disse que no dia dos fatos, conversou com a ré justamente para informar que não precisaria de seus serviços, ocasião em que ela lhe pediu o favor de entregar uns papéis para um rapaz de vulgo "cadeira" do pavilhão h. Aduziu que as folhas não estavam a mostra, mas dentro de duas folhas brancas. Informou que quando chegou na inclusão, a pedido do agente retirou suas vestes e colocou os papéis em cima de um banco, e quando o agente abriu o papel viu as folhas amareladas. Aduziu que não sabia o que estava carregando e que nunca havia visto esse tipo de substância.

Quando interrogado, em Juízo, o réu João fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Na fase inquisitiva o réu João afirmou foi para o parlatório conversar com a corré Antônia, sendo que esse foi o primeiro contato que teve com ela. Aduziu que a corré Antônia pediu que entregasse quatro folhas a um rapaz que apareceria no término do atendimento, e que isso serviria para abater a

sua dívida. Disse que colocou as folhas na cintura e quando estava descendo foi abordado por um agente penitenciário que o revistou e encontrou as 4 folhas da droga conhecida como K4.

Quando interrogada, em Juízo, a ré Antônia negou os fatos. Afirmou que foi até o presídio para entrevistar João e Felipe. Contou ter sido normalmente revistada e passado pelo scanner corporal. Informou que entrou na penitenciária apenas com uma caneta e com a carteira da OAB. Contou que conversou com os réus sendo que um deles informou que não precisaria mais de seus serviços. Aduziu que quando saiu do parlatório, um funcionário pediu para que aguardasse o diretor do presídio. Contou ter sido informada pelo diretor da penitenciária que foram encontrados com os detentos com quem conversou no parlatório substância entorpecente. Falou que o diretor acionou a polícia militar e um representante da OAB. Disse que chegou na penitenciária acompanhada de um taxista, que inclusive foi com o agente penitenciário até a delegacia. Informou que foi acompanhada pela polícia militar até a delegacia. Negou ter entregado qualquer papel aos detentos. Informou que o taxista narrou que os agentes penitenciários entraram no veículo e colocaram alguns papéis dentro da bolsa que estava no veículo.

A negativa da ré, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O agente penitenciário José Reinaldo Maracajá da Silva, em Juízo, afirmou que no dia dos fatos estava escalado para trabalhar na "gaiola". Contou que a acusada Antônia fazia atendimento com dois presos. Aduziu que de onde estava, tem uma porta com janela de vidro, em razão disso, presenciou o momento em que o réu pegou algo da advogada, virou-se para o lado esquerdo e colocou rapidamente no bolso. Narrou que entrou em contato com o agente José Eduardo e, juntos, abordaram o réu e, após revista, localizaram o entorpecente K4 em suas vestes. Informou que o segundo preso demorou bastante no atendimento, mas também foi revistado assim que saiu e, em suas vestes, localizaram também folhas da substância K4. Afirmou que informou a diretoria da penitenciária, que acionou a advogada. Narrou que a polícia foi acionada. Disse que a revista na bolsa da acusada foi feita apenas na delegacia, e nela foram localizadas mais folhas com a mesma descrição, cor e escrito "EKOS". Informou que a advogada foi abordada assim que saiu do parlatório, momento em que a diretoria fez o contato com a polícia e a OAB para o acompanhamento. Afirmou que ao serem indagados, os acusados João e Felipe apresentaram várias contradições. Relatou que já realizou outras apreensões de K4 na penitenciária. Contou que o preso apresentou nervosismo, o que gerou suspeita da ação. Informou que já é agente penitenciário há 33 anos. Disse que não sabe relatar se a ré teve sua pasta revistada antes de ingressar no parlatório.

O agente penitenciário José Eduardo Oliveira Souza, em Juízo, afirmou que estava na inclusão e foi chamado via rádio por um funcionário que estava na gaiola, informando que um preso recebeu algo de uma advogada dentro do parlatório. Contou que ao chegar ao local revistou o preso que estava conversando com a advogada e achou em suas vestes algumas folhas amarelas. Disse que outro preso que falou que falou com a advogada foi revistado e com ele encontraram, também, folhas amareladas escondidas nas vestes. Relatou que comunicou o diretor geral da unidade, que convocou a OAB, e todos foram encaminhados à delegacia. Narrou que a ré foi até a penitenciária de táxi, e que a bolsa dela, que estava no veículo, foi revistada na delegacia, e foram localizadas em seu interior mais folhas, iguais às encontradas com os dois presos. Afirmou que a advogada foi abordada na portaria, e que o taxista estava esperando a ré do lado de fora da penitenciária. Contou que estava presente quando a bolsa da ré foi revistada. Informou que ao serem indagados, os réus afirmaram que a ré havia entregado as folhas amareladas conhecidas como K-4. Reconheceu os réus como sendo os que revistou no dia dos fatos. Aduziu que nas folhas amareladas encontradas estava escrito "EKOS", igual ao escrito das folhas encontradas com os presos. Disse que a distância entre a portaria e o parlatório é

de 30 a 40 metros. Afirmou acreditar que todos os procedimentos de scanner foram realizados na entrada da ré na penitenciária, mas não presenciou a revista da ré ao entrar na penitenciária. Aduziu que trabalha como agente penitenciário há 10 anos, e na referida penitenciária onde ocorreu os fatos exerce suas funções há 08 anos.

A testemunha Edinaldo Francisco da Silva, na fase inquisitiva, afirmou ser taxista. Contou que já havia transportado anteriormente a advogada Antônia, tendo a levado para fóruns e penitenciárias. Afirmou que na data dos fatos levou Antônia ao CPP Ataliba Nogueira em Campinas. Disse que ela levava consigo uma bolsa feminina, desconhecendo o que havia na bolsa. Aduziu que chegando ao CPP Ataliba Nogueira, Antônia avisou que iria conversar com alguns presos e voltaria em alguns minutos, deixando a bolsa no chão do veículo, na parte traseira. Falou que logo em seguida, agentes penitenciários vieram até o veículo e indagaram sobre Antônia. Narrou que contou aos agentes que a bolsa que estava em seu veículo pertencia a Antônia. Afirmou que acompanhou a revista na bolsa de Antônia a distância, e não viu se algo ilícito foi encontrado.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas, nas dependências de estabelecimento prisional, imputado à ré Antônia. Ela trazia consigo e entregou aos detentos JOÃO MAURÍCIO COUTINHO GUIMARÃES JÚNIOR e FELIPE FERNANDES BARBOSA respectivamente, 04 (quatro) segmentos de papel de cor branca, contendo ADB-BUTINACA, constante da lista F2 (Lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) por sua classe estrutural dos canabinoides sintéticos da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), droga popularmente conhecida como "K4", e 09 (nove) segmentos de papel de cor amarela, contendo a mesma substância conhecida como "K4", pesando 34,9g (trinta e quatro gramas e nove decigramas), sendo que, no interior de um veículo "taxi", estacionado próximo ao presídio, ANTONIA DE FERREIRA CARVLHO BAUDUINO também transportava e guardava, para fins de tráfico, mais 03 (três) segmentos de papel de cor amarela, contendo a substância ADB-BUTINACA, pesando 40,1g (quarenta gramas e um decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Os agentes penitenciários afirmaram que acusada Antônia compareceu ao presídio para atendimento a dois sentenciados. A testemunha José Reinaldo afirmou que através de uma janela de vidro existente na porta viu quando a acusada entregou a um dos sentenciados folhas, tendo ele as colocado em suas vestes. Afirmou que assim que o sentenciado saiu do atendimento, foi abordado e revistado, sendo encontrado em seu poder folhas da substância conhecida como K4. Contou, ainda, que o segundo sentenciado também foi revistado assim que deixou o parlatório, e com ele foram localizadas mais folhas da mesma substância. Disse, por fim, que a bolsa da ré foi vistoriada na delegacia de polícia, e em seu interior foram encontradas mais três folhas idênticas às localizadas com os sentenciados, inclusive co a mesma inscrição "EKOS". O agente penitenciário José Eduardo, por sua vez, contou ter sido acionado para comparecer ao setor de inclusão, uma vez que um detento havia recebido algo suspeito de uma advogada. Contou que foi até o local e revistou o sentenciado, com quem foram encontradas as folhas contendo K4. Afirmou, ainda, que ambos os sentenciados afirmaram terem recebido as folhas da acusada Antônia, que lhes pediu para entregar para outro indivíduo preso no local.

O depoimento dos agentes penitenciários restou confirmado pela fala dos corréus Felipe e João, que confirmaram terem recebido as folhas da acusada Antônia, embora desconhecessem que se tratava de entorpecente.

Por fim, a testemunha Edinaldo, na fase inquisitiva, contou ser taxista e ter conduzido a ré até o presídio, confirmando que ela deixou no carro uma bolsa feminina que, posteriormente, foi vistoriada por policias

Não se pode desmerecer os depoimentos dos agentes penitenciários. São eles agentes

do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A negativa da ré Antônia restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas. Em primeiro pelo depoimento dos corréus, que confirmaram terem recebido de Antônia as folhas, que deveriam ser entregues a outro preso. Em segundo pelo depoimento dos agentes penitenciários, que afirmaram terem visto a ré entregando as folhas aos detentos. Por fim, diferentemente do afirmado pela acusada, a testemunha Edinaldo nada informou, em seu depoimento, sobre agentes penitenciários terem coloca folhas na bolsa da acusada que estava em seu carro. Ao contrário, a testemunha apenas afirmou que os agentes pegaram a bolsa que estava no carro e a levaram para que fosse vistória.

Assim, a negativa da ré restou totalmente desmentida pelas provas produzidas.

Restou comprovada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, uma vez que a prova demonstrou ter sido o crime praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a

desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial em relação à acusada Antônia.

Por outro lado, em relação aos acusados JOÃO MAURÍCIO COUTINHO GUIMARÃES JÚNIOR e FELIPE FERNANDES BARBOSA, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são insuficientes à prolação de uma sentença penal condenatória.

Quando interrogados (em Juízo o réu Felipe e na fase inquisitiva o réu João), ambos os acusados negaram a prática delitiva. Contaram que passaram por atendimento no parlatório, com a acusada, que lhes pediu para que entregassem folhas para um detento preso no mesmo estabelecimento prisional. Afirmaram que aos passaram pela revista, os agentes encontraram em poder deles as folhas contendo a substância entorpecente K4. Ambos os réus afirmaram desconhecer que dentre as folhas que lhes foram entregues pela ré havia substância entorpecente proibida.

Corroborando a versão apresentada pelos réus, os agentes penitenciários confirmaram que viram a ré entregando aos acusados folhas de papel. Disseram que logo após o atendimento recebido, ambos os réus foram revistados e, dentre as folhas que eles traziam consigo, encontraram papéis amarelados que, posteriormente, confirmou-se, continham a substância entorpecente conhecida como K4.

Desta forma, embora haja indícios de que os réus, conluiados com a corré Antônia, estivessem na prática do tráfico de drogas, não há prova cabal do dolo por parte dos acusados que podem, efetivamente, terem recebido os papéis sem o conhecimento de que se tratava de entorpecente. Assim como é possível que eles tenham recebido os papéis conscientes de que se tratava de substância entorpecente, é possível, também, que tenham recebido achando que se tratava apenas de papéis, que deveriam ser entregues a outro detento. E em direito penal, como é sabido, em caso de dúvida, ela deve ser resolvida em favor do acusado.

A condenação criminal somente pode ser lavrada diante de prova cabal, segura e indubitosa, que não deixe no espírito do julgador qualquer dúvida. Não sendo deste modo, a absolvição é de rigor.

Passo a dosar a pena em relação à acusada Antônia

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto não haver agravantes ou atenuantes. A ré é tecnicamente primária (fls. 295/300).

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, aumento a pena em um sexto, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase, sendo a acusada Antônia primária e não havendo prova concreta de que integre organização criminoso, além de não haver qualquer prova no sentido de que ele se dedique ao tráfico de forma contumaz e permanente, considerando, ainda, que a quantidade de entorpecente com ele encontrada não é expressiva e/ou diversificada, nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 (dois terços) resultando, em definitivo, 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Cabe destacar que em caso análogo, no qual o réu transportava cerca de 990 gramas de cocaína, houve determinação do STF, em sede Recurso Ordinário de Habeas Corpus n. 197905, para aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do

artigo 33, da Lei 11.343/06. Há vários outros precedentes desta Corte e do STJ neste sentido, ou seja, quantias mais expressivas de droga com o reconhecimento do privilégio.

Também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da atual jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixada, quando do julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, a elevada quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. Portanto, inexistentes outras características da conduta deletéria aptas a amparar conclusão nesse sentido, tal como ocorreu na espécie, não há falar em afastar o benefício ou modular a fração dessa aquém do mínimo legal. 2. Agravo regimental desprovido.". (STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 , julgado em 17/08/2021)" - grifei

No mesmo sentido decidiu o TJSP, em julgamento de caso originado nesta Vara Criminal, apreensão de 5,77 kg de maconha ao dispor que: "Porém, em que pese estivesse o réu a transportar expressiva quantidade de droga, quase seis quilos, a prova produzida na instrução nada revelou quanto ao envolvimento dele com organização criminosa ou que se dedicasse com habitualidade à prática de crimes, motivo pelo qual cabe aplicar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, adotando-se o índice de um sexto, considerada a quantidade do entorpecente, que permitiria atingir grande número de usuários, de tal modo a se alcançar um total definitivo de quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, o que inviabiliza a imposição de sanções alternativas, as quais, na hipótese, nem seriam socialmente recomendáveis" (Apelação Criminal 1500824-89.2020.8.26.0548; Relator: Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2020) - grifei.

Por fim, em caso análogo, também em julgamento de caso originado nesta Vara Criminal, apreensão de 838 porções de cocaína, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de drogas Materialidade e autoria demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Pena-base fixada no mínimo - Confissão do réu - A quantidade de drogas somente deve ser considerada na primeira fase de aplicação da pena e não impede a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Regime aberto Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa - RECURSO DA DEFESA PROVIDO" (Apelação Criminal 1501577-46.2020.8.26.0548; Relator: Heitor Donizete De Oliveira ; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19 de outubro de 2021) - grifei.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré ANTÔNIA FERREIRA DE CARVALHO BALDUÍNO a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ABSOLVER os réus FELIPE FERNANDES BARBOSA e JOÃO MAURÍCIO COUTINHO GUIMARÃES JÚNIOR da imputação que lhes foi lançada na peça acusatória.

O regime inicial de cumprimento de pena para a ré Antônia, tendo em vista o

montante da pena fixado e, também, levando em consideração tratar-se de tráfico privilegiado e de pequenas proporções, será o ABERTO. Poderá a acusada aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Ainda, anoto ser possível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Justifico.

O Supremo Tribunal Federal (HC 97.256) reconheceu a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da lei 11.343/06 (...vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos). Vale frisar, inclusive, que a Corte maior no julgamento do HC 111.840 declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei 8.072/90, o qual prevê que a pena para o crime de tráfico será cumprida inicialmente em regime fechado. Vale citar alguns julgados sobre o tema: "(...) a partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do referido HC nº 97.256/RS, em que se admitiu a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, impõe-se, neste caso, a adequação também do regime, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da sanção penal, com a fixação de regime prisional mais brando, compatível com a benesse concedida justamente para evitar o encarceramento" (STJ, HC nº 237.074/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.5.2012). "Nesse contexto, nas hipóteses em que se verificar a viabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em medida restritiva de direitos, não deve existir impedimento para a fixação do regime inicialmente aberto no cumprimento da pena." (STJ, HC 213.288/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 22.5.2012). "(...) a Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com previsto no art. 33 do Código Penal (HC nº 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), bem como a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos." (STJ, HC nº 189.931/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.5.2012). "Ocorre que, em recentes julgados, esta Segunda Turma concedeu a ordem a pacientes condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com afastamento da regra do art. 2º, §1º, da Lei. 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determina o cumprimento no regime inicial fechado, para permitir-lhes que iniciem o cumprimento das suas reprimendas no regime aberto, porque presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art.33, II, c, do Código Penal" (STF, HC 109.343/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, v.u., j.03.4.2012)".

Mais recentemente, o STF reconheceu no julgamento do Habeas Corpus 125.188 a possibilidade de concessão de regime aberto com substituição da pena corporal pela restritiva em casos de tráfico privilegiado. Ainda, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 600, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou entendimento, aliando-se ao que foi decidido pelo STF no HC 118.533/MS, que o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo.

Assim, ante tais decisões da Corte Suprema e do STJ, o magistrado deve analisar, caso a caso, os requisitos legais para a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, especificados no artigo 44 do Código Penal. Dispõe o inciso VI do mencionado artigo ser possível a substituição quando todas as circunstâncias previstas forem favoráveis, inclusive culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Não se olvide que o tráfico de drogas é o tipo de crime em que seus agentes estão sempre escalonados em hierarquia que vai dos pequenos traficantes de rua aos grandes chefes que comandam uma organização. Assim, é necessário aferir, no caso concreto, qual a situação exata do condenado.

No caso em tela, verifica-se ser o tráfico apurado de pequenas proporções, não sendo expressiva a quantidade de droga apreendida. Ainda, não há prova de que a sentenciada integre organização criminosa e seja dela membro importante ou ocupante

de função de relevo. Por fim, foi reconhecido o tráfico privilegiado. Portanto, possível a substituição da pena corporal ante o preenchimento de todos os requisitos legais.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade assistencial a ser indicada pelo juízo da Execução.

Por fim, anoto que se a situação concreta do condenado e as circunstâncias do crime fossem outras, a fixação da pena e a substituição poderiam não ter ocorrido.

Custa na forma da lei.

Decreto a perda dos valores apreendidos.

Após o trânsito em julgado, intime-se a ré para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 17 de agosto de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA